

1576802-06.2022.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... de idade, teve passagem na Fundação Casa, por tráfico de drogas. Ficou 10 meses internado. Teve 3 passagens quando menor de idade. Todas por tráfico de drogas. Além da internação na Fundação Casa, cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida. Conhece o outro réu (Matheus Henrique Santos Silva Campos) há cerca de 9 a 10 anos. Participou dos assaltos. Era o motorista. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1576802-06.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1576802-06.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2015910/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 16574949 - 04º D.P. GUARULHOS, 6356/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 6364/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2015910 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MATOS PACHECO ALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra os réus EDUARDO MATOS PACHECO ALVES, qualificado a páginas 67/68, e MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS, qualificado a páginas 76/77, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas, na Rua São Bartolomeu, 222 Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Hella

Souza Rodrigues, um veículo MMC/PAJERO TR4 FLEX, placas DYA6566; R\$600,00 em espécie; 01 relógio de pulso, da marca Apple, modelo 12 (cf. descrito no RDO 6377/2021).

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 29 de dezembro de 2021, logo após o roubo acima descrito, na Rodovia SP 070 Ayrton Senna, 26 - Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, EDUARDO MATOS PACHECO ALVES qualificado páginas 67/68, e MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA CAMPOS, qualificado a páginas 76/77, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Idebrandes dos Santos Niza, um veículo GM/Onix, placas FBX0F20; 01) aparelho de telefonia celular da marca Xiaomi; documentos pessoais; bem diversas ferramentas de trabalho (cf. descrito no DO 6356/2021).

Segundo o apurado, no dia 29 de dezembro de 2021, a vítima Helia Souza conduza seu veículo Pajero, placas DYA6566, pela via pública, momento em que foi abordada pelos acusados EDUARDO MATHEUS e um terceiro comparsa, os quais faziam uso de um veículo Fiat/Uno, placas BIF 9789.

Ato contínuo, EDUARDO e MATHEUS, ambos armados, desembarcaram do veículo Fiat/Uno e anunciaram o roubo, entrando em seguida no veículo Pajero da vítima Helia Souza, arrebatando-a para o banco traseiro, local em que ficou mantida sob refém de EDUARDO.

Em seguida, os acusados passaram a trafegar com o veículo da vítima, exigindo que ela realizasse transferências bancárias, no entanto, como não tinha valor em conta, os roubadores subtraíram R\$ 600,00 em espécie que ela trazia consigo, bem como seu relógio e o veículo Pajero.

Não satisfeitos, logo em seguida ao roubo acima perpetrado, os acusados, fazendo uso da Pajero subtraída e do veículo Fiat/Uno, após visualizarem a vítima Idebrandes conduzindo seu veículo GM/Onix, colidiram contra o veículo por ela conduzido, fazendo com que ela descesse do automóvel.

Ato contínuo, um dos meliantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que Idebrandes entregasse seus bens, tendo ele ingressado no veículo da vítima e se evadido, seguido pela Pajero. O Fiat/Uno, por sua vez, foi abandonado pelos meliantes.

Realizada perícia papiloscópica no veículo Fiat/Uno abandonado, foram encontradas as digitais do acusado EDUARDO.

Em continuidade às investigações, a vítima do roubo do veículo Pajero, Sra. Helia, compareceu ao DP e reconheceu os acusados como dois dos autores do delito (fls.63/64).

Denúncia recebida às fls. 105.

Citados (fls. 159 e 160), os acusados apresentaram defesa escrita (fls. 171).

Ratificado o recebimento da denúncia às fls. 174/175.

Em audiência de instrução os acusados foram interrogados após a oitiva de duas vítimas (fls. 205).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se os acusados nos termos da denúncia (fls. 200/204).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados por insuficiências de

provas. Caso condenados, apresentou teses subsidiárias (fls. 200/204).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade dos delitos e suas autorias são indúvidas.

A materialidade dos delitos de roubo qualificado ficou demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 27/28 (vítima Helia), fls. 07/09 (vítima Idebrandes), laudo pericial papiloscópico de fls. 14/18, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

A vítima do primeiro roubo, Helia, ouvida em Juízo, narrou a dinâmica do assalto da mesma forma como descrita na denúncia, inclusive a utilização de arma de fogo pelos ladrões, bem como reconheceu os acusados pessoalmente, assim como fizera em sede policial (fls. 29, 46, 67 e 68): "A vítima foi assaltada no dia, 29 de dezembro de 2021. Estava no veículo Pajero. O assalto ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Eram 3 assaltantes. Um ficou no carro Uno e dois a abordaram. O carro dos assaltantes era um fiat Uno modelo antigo. Pelo que se recorda, era azul claro. Estavam armados. Ao se aproximarem para abordar a vítima, pediram para puxar o freio de mão. Obrigaram-na a ficar no banco traseiro do carro. Ficou refém dos assaltantes por volta de 15 minutos. Tentaram realizar transferência bancária, via PIX, porém não foi possível, porque a vítima não possuía dinheiro em sua conta. Os assaltantes levaram seu relógio, que valia cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais), R\$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e seu veículo Pajero. A vítima chegou a recuperar seu veículo, após 38 dias do assalto. O veículo estava avariado, sem a placas, batido e o motor foi modificado. Não possuía seguro. Gastou cerca de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para arrumar o veículo. Até o momento, não conseguiram em emplacar o carro. Ninguém foi preso no dia do assalto. A vítima realizou reconhecimento dos assaltantes, após alguns dias do roubo. Fez reconhecimento pessoal no Primeiro Distrito Policial de Guarulhos. E em outro momento, fez reconhecimento por fotografias. Teve a oportunidade, de reconhecer os dois assaltantes, durante o reconhecimento pessoal. Em audiência, reconhece os acusados novamente como autores do assalto sofrido".

A vítima do segundo roubo, Idelbrandes, ouvido em Juízo, também narrou o assalto sofrido, igualmente com utilização de arma de fogo. Os meliantes ocupavam um veículo Pajero e outro Fiat/Uno. Subtraíram seu veículo Onix. Fugiram no Onix e na Pajero, abandonando o veículo Uno. Por fim, disse não conseguir reconhecer os meliantes, pois utilização máscaras no momento do assalto: "A vítima foi assaltada no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas da manhã. Estava sozinho em seu veículo Onix. Os assaltantes bateram em seu veículo. Eles estavam em 4 indivíduos. O assaltante que abordou a vítima estava armado. Estavam em dois carros: uma Pajero e um Uno. Quando entrou na rua estes dois carros estavam parados. A vítima parou atrás deles. A Pajero deu ré e acabou batendo em seu carro. A vítima desceu do veículo para tirar foto da placa. Neste momento, anunciaram o assalto. Levaram todos os seus pertences, incluindo suas ferramentas de pedreiro e o seu veículo Onix. Durante o assalto, abandonaram o Uno. Não recuperou nenhum pertence. Possuía seguro. Teve um prejuízo de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda está pagando os quatro pneus do carro. No dia nenhum assaltante foi preso. Não fez reconhecimento por fotografia, nem pessoalmente. Diz que não poderia reconhecer os indivíduos, porque estavam de máscara".

Em se tratando de roubo, a palavra da(s) vítima(s) tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a

autos elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Não há qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento operado pelas vítimas, seja na delegacia, seja em Juízo.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Nesse sentido, observa-se decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que "não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o

reconhecimento, pois o artigo 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial" (Relator Ministro Gilson Dipp - HC nº 7.802-RJ, 5a Turma, j . 20.05.1999, v.u., DJU 21.06.1999, p. 172).

Nem se alegue eventual "inobservância" ao item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 que dispõe: "Entendendo o magistrado sobre a necessidade da aplicação do inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando da comunicação da data e horário da audiência ao estabelecimento prisional, tal circunstância será informada ao estabelecimento prisional para que além do réu, se possível, sejam apresentadas duas outras pessoas que guardem com ele semelhança".

Por primeiro, comunicado não é lei, não substitui o Código de Processo Penal nem o regulamenta. Além disso, da leitura atenta do texto por qualquer pessoa de inteligência mediana, depreende-se que o procedimento não é obrigatório. Será utilizado apenas quando o magistrado entender necessária a aplicação do art. 226, CPP, o que não é o caso, como acima esposado.

Essa celeuma fica ainda mais sem sentido no caso em tela, em que o réu EDUARDO confessou os roubos perpetrados, como se verá a seguir

Não há motivo para desmerecer as palavras das vítimas.

De fato, não se vislumbra por qual motivo as vítimas prestariam falso testemunho, incriminando injustamente os réus, pessoas que sequer conheciam até a data dos fatos.

O acusado EDUARDO, ouvido em Juízo, admitiu sua participação em ambos os assaltos, mas negou participação do corréu Matheus: "Tem 21 anos. É amasiado. Tem dois filhos. Estudou até o terceiro ano. Quando foi preso, trabalhava em uma oficina. Não era registrado. Ganhava R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Não é usuário de nenhum entorpecente. Tem passagem por, porém foi absolvido, por falta de provas. Quando menor de idade, teve passagem na Fundação Casa, por tráfico de drogas. Ficou 10 meses internado. Teve 3 passagens quando menor de idade. Todas por tráfico de drogas. Além da internação na Fundação Casa, cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida. Conhece o outro réu (Matheus Henrique Santos Silva Campos) há cerca de 9 a 10 anos. Participou dos assaltos. Era o motorista. Matheus não participou dos assaltos. Prefere não revelar os outros assaltantes, para não se comprometer. Os outros assaltantes moram próximo de sua casa. Não sabe a idade que os demais assaltantes possuem. O veículo Fiat Uno era de um deles".

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão do acusado EDUARDO encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente o encontro de suas digitais no veículo Fiat Uno utilizado em ambos os roubos (laudo pericial papiloscópico de fls. 14/18).

O acusado MATHEUS, por sua vez, ouvido em sede policial, preferiu permanecer calado (fls. 70).

O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito inclui-se até mesmo a prerrogativa processual de o acusado negar, ainda que falsamente, perante a autoridade policial ou judiciária, a prática da infração penal.

Porém, não se pode olvidar que a postura de permanecer calado mostra-se incompatível com aquela de quem se diz inocente. Este, por óbvio, clama por seu estado de inocência quando é preso.

A propósito:

PROVA – INTERROGATÓRIO POLICIAL – SILÊNCIO DO RÉU – EFICÁCIA – O silêncio do réu, por ocasião de seu interrogatório na polícia, é atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo assim a oportunidade de esclarecer, de pronto, algum equívoco de seus acusadores. (TACRIMSP – AP 1.048.433 – 15ª C – Rel. Juiz Fernando Matallo – J. 22.05.1997)

“A menos dê o acusado convincentes razões de sua inopinada mudez na fase do inquérito, será força interpretá-la por indício grave de culpa. É que nenhum inocente, que deveras o seja, deixa correr, sem protesto enérgico, injusta acusação; suposto seja direito do réu permanecer calado no interrogatório, paga contudo alto preço por isso decai da oportunidade de justificar-se perante quem o acusa. E, nas mais das vezes, este silêncio é confissão tácita de culpa. (TACRIMSP – AP 1.039.941 – 15ª C – Rel. Juiz Carlos Biasotti – J. 06.03.1997)

Ouvido em Juízo, MATHEUS negou sua participação nos assaltos, de forma simplista, sequer sabendo informar onde estava no dia e horário dos roubos (29.12.21, por volta das 10:00h): “Tem 25 anos. É amasiado. Não possui filhos. Estudou até a sexta série. Trabalhava na feira. Ganhava cerca de R\$ 50,00 à R\$ 100,00 reais, por trabalho. Teve passagem por assalto, porte de arma, receptação. Ficou cerca de 3 anos presos. Saiu da cadeia há 4 meses. Cumpria regime aberto. Teve passagem como menor de idade por furto, porte de arma e roubo. Ficou internado na Fundação Casa, por 2 anos. Conhece o outro réu (Eduardo Matos Pacheco Alves), há cerca de 4 meses. Não participou dos assaltos. Não lembra com exatidão onde estava no dia 29 de dezembro de 2021. Não sabe explicar por que foi reconhecido pela vítima Helia. Garante que não cometeu o crime que está sendo acusado neste processo. Alega que foi preso em “outra situação”, junto com o Eduardo, porém não estava neste caso. Estava na delegacia com o Eduardo e acabou sendo associado ao crime em tela”.

As palavras do acusado MATHEUS, além de inverossímeis, restaram isoladas no conjunto probatório carregado aos autos.

O acusado sequer soube informar onde se encontrava na data dos fatos.
Patético.....

Observe-se que, no caso em tela, a vítima Helia reconheceu o acusado MATHEUS em Juízo, sob o crivo do contraditório, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo, como já fizera em sede inquisitorial, não apenas através de fotografias, como também pessoalmente (fls. 29, 46, 67 e 68).

Como já dito, não se vislumbra por qual motivo a vítima Helia prestaria falso testemunho, incriminando injustamente o acusado MATHEUS.

A participação do acusado MATHEUS no segundo assalto é igualmente indene de dúvida, pois os roubos aconteceram na sequência, com poucos minutos de intervalo e em locais muito próximos.

No segundo assalto, aliás, foi utilizado o veículo Pajero subtraído minutos antes da vítima Helia.

Também não se pode olvidar que MATHEUS foi preso junto com Eduardo, em uma tentativa de latrocínio ocorrida no dia 04.04.22, poucos dias após a data dos roubos em tela.

Como se vê, além de não comprovada, a negativa do acusado MATHEUS não merece ser levada em conta, isto porque nada trouxe que afastasse dele a responsabilidade pelas subtrações ora apuradas, limitando-se a fazer alegações vagas e sem elementos probatórios que as comprovassem, ao contrário das narrativas trazidas pelas vítimas, que apresentam sequência lógica e coesa.

Não há dúvida, portanto, quanto à participação do acusado MATHEUS nos assaltos narrados na denúncia.

As causas especiais de aumento de pena referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes devem ser reconhecidas.

O concurso de agentes restou indubitável diante da narrativa das vítimas.

Embora não apreendida a arma de fogo utilizada nos assaltos, ambas as vítimas foram categóricas ao narrar que os meliantes portavam arma de fogo.

A palavra firme e segura da(s) vítima(s), no delito de roubo, basta para o reconhecimento da aludida majorante.

A propósito:

STJ “Para a aplicação da circunstância qualificadora do uso de arma de fogo no crime de roubo, é dispensável a apreensão do artefato, mormente se sua utilização para perpetração do delito pode ser provada por outros meios, entre eles o depoimento de testemunhas ou da própria vítima” (RT 841/515)

STJ “É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do artigo 157, do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima” (RT 821/534).

Embora ambas as causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de agentes) estejam devidamente comprovadas, somente é possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

A segunda majorante, relativa ao concurso de agentes, somente pode ser considerada na dosagem da pena como circunstância do delito, nos termos do art. 59, CP.

Convém lembrar, a Lei n. 13.654/18 não padece de inconstitucionalidade formal.

Na verdade, como se verá a seguir, houve equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Trata-se, portanto, de mera irregularidade, que não tem o condão de viciar o processo legislativo.

A mens legislatoris desde sempre foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal objetivo foi, de fato, alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Artigo publicado no site "Só Notícias" da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Procurador de Justiça (MP/MT), explica minuciosamente o equívoco cometido e que gerou toda a celeuma em torno do art. 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, designadamente no que concerne ao seu artigo 4º, o qual revogou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Como já se sabe, o aludido diploma normativo, entre outras inovações inseridas no Estatuto Repressivo, introduziu o § 2º-A ao artigo 157 (tipo penal de roubo), aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços) quando o delito envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, no cometimento da infração. Por outro lado, o novel diploma legal, como dito, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3 (um terço) a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego de arma (lato sensu), abrangendo, pois, todo e qualquer artefato possível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele próprio (revólver, faca, espada, etc.) ou impróprio (pedra, barra de ferro, porrete, etc.).

Contudo, na aurora da vigência da novel lei, alguns estudiosos têm apontado um suposto vício de constitucionalidade no referido documento normativo. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. A ementa do julgado é a seguinte:

TJSP: "ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO - APELAÇÃO - Pleito Ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma (branca) - Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I do §2º do art. 157 do CP - RECONHECIDA a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 - SUSPENSO o julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO da instauração de incidente de inconstitucionalidade com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça". (Apelação Criminal com Revisão nº 0022570-34.2017.8.26.0050. Quarta Câmara Criminal. Rel. Des. Edison Brandão. Data de Julgamento 08/05/2018).

Inclusive, na esteira desse entendimento, as Chefias dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (04), de Mato Grosso do Sul⁵ e Goiás⁶, recomendaram aos membros das respectivas Instituições, ainda que de maneira não vinculante, que, em sede de controle difuso, arguissem a inconstitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, segundo argumentam, haveria afronta ao devido processo legislativo na tramitação do Projeto de Lei (PLS 149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.

Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015, aprovado, inicialmente, pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu) conforme, depois, constou no artigo 4º da Lei 13.654/2018. Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no Projeto de Lei, em desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente, aprovado pelo plenário daquela comissão, e que,

posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação, configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, a celeuma toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, para bem demonstrar esse lapso, importa promover aqui uma análise detalhada da tramitação do projeto de lei, a partir de consulta nos websites do Senado (07) e da Câmara Federal (08), algo que poderá ser entediante, porém necessário.

Pois bem. Consta que no dia 24/03/2015, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que, a um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena na hipótese de crimes de roubo, quais sejam, quando durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 1º) e, por outro lado, revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma (art. 3º)⁹. Importante notar, prontamente, que desde a proposta inicial estava clara e taxativa a intenção de derrogar a cogitada causa de aumento de pena anteriormente prevista no Código Penal.

O projeto, que tramitou na forma do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno do Senado Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antonio Anastasia, emitiu parecer pela aprovação da proposta (10), tal qual apresentada pelo proponente.

A matéria foi incluída na pauta da CCJ e, então, na sessão do dia 13/09/2017, após a leitura do relatório do Senador Antonio Anastasia, foi concedida vista do projeto aos Senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin. Não houve, portanto, naquela sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei (11).

A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a Senadora Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 0112, que, a rigor, nada alterou a proposta original no ponto em que revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Naquela mesma sessão, o Senador Antonio Anastasia reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e, posteriormente, o plenário da cogitada comissão aprovou¹³ o texto do Projeto de Lei – Parecer (SF) 141/2017¹⁴ –, tal qual formulado pelo seu proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela Senadora sul-matogrossense.

Contudo, o Parecer (SF) nº 141/2017, ao ser publicado no Diário do Senado Federal (15), certamente por algum lapso, não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa, conforme já foi dito, a revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aqui, aparentemente, repousa o ponto nodal de toda a celeuma, qual seja, o descompasso entre o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto publicado no Senado Federal, que, repita-se, não retratou aquilo que foi deliberado.

Fato é que, na sequência, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE (Comissão de Redação Legislativa), que, ao que consta, recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, isto é, contendo o dispositivo que revogava a majorante que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma (lato sensu) (16).

Posteriormente, o texto aprovado (17), que continha a revogação da majorante, e, porquanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado Federal, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL 5.989/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho, que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da Casa da Federação (18).

Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento (19). Isto quer dizer que a única alteração material feita pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Aliás, a derrogação da aludida causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se intocável, e restou prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa Revisora.

Em seguida, no dia 06/03/2018, o Projeto de Lei – que, naturalmente, continha a revogação da majorante em seu artigo 4º – sob a rubrica de Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, retornou à Casa Iniciadora (20) onde foi aprovado pelo Plenário²¹.

Empós, como de rigor, encaminhou-se o texto aprovado para a sanção do Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada²².

Como se pode ver, a revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, além de constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no Texto Final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se reconhecer que a apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que, como visto, não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que há de merecer o timbre de mera irregularidade, não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como inconstitucional o sobredito preceito. A propósito, é de ver que a mens legislatoris desde sempre, foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal desiderato, ao final e ao cabo, foi alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Convém registrar, por último, que, apesar de não conter qualquer vício de constitucionalidade formal, o artigo 4º da Lei 13.654/2018, representa, inequivocamente, grave redução no nível de proteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, afinal, a experiência aponta, ao sobejo, que o crime de roubo, comumente, é praticado tanto com armas de fogo, como também com o emprego de outras armas – próprias ou impróprias –, circunstância que, além de diminuir a possibilidade de reação da vítima, eleva a potencialidade da ameaça e da violência.

Assim, ante esse decréscimo do nível de proteção, abre-se a possibilidade de se questionar eventual violação do Princípio da Proporcionalidade na perspectiva da Proibição de Proteção Deficiente. Mas, claro, esse é um outro lado da moeda e, porquanto, há de ser discutido oportunamente.

Domingos Sávio de Barros Arruda – Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Procurador de Justiça (MP/MT).

Victor Lucas Alvim – Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Oficial de Gabinete (MP/MT).

03. <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI0046PXE0000#?cdDocumento=35> . Acesso em 16 maio 2018.

04. <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/COMUNICADO%20CAOCrim%20AVISO%20162%202018.docx> . Acesso em 16 maio 2018.

05. <https://www.mpms.mp.br/noticias/2018/05/procurador-geral-de-justica-do-mpms-aponta-inconstitucionalidade-em-lei-que-extingue-majorante-de-roubo-com-arma> . Acesso em 16 maio 2018.

06. <http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/nota-tecnica-do-mp-alerta-para-vicios-em-artigo-de-lei-que-altera-punicao-de-crime-com-uso-de-explosivo#.WwMXg-7RWM8> . Acesso em 21 maio 2018.

07. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/120274> . Acesso em 16 maio 2018.

08. <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149> . Acesso em 16 maio 2018.

09. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599802&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

10. O arquivo pode ser baixado neste link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599811&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

11. Trata-se da 37ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h37min15seg até 01h40min43seg do vídeo.

12. O arquivo pode ser encontrado no seguinte link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

13. Trata-se da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=6919&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h00min até 01h18min do vídeo.

14. No website do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, pode-se fazer o download do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, no qual se tem o Parecer do relator, a Emenda aditiva, o Relatório de Registro de Presença da CCJ naquela data, a Lista de Votação Nominal, o Texto Final aprovado e a Decisão da Comissão. Conferir o seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

15. O Parecer (SF) Nº 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do dia 10/11/2017 (páginas 133 a 143) não trouxe, no Texto Final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da malfadada majorante (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário Oficial do Senado do dia 10 de novembro de 2017 pode ser baixado no seguinte link: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#> . Acesso em 16 maio 2018.

16. Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado

Federal, na seção de "Tramitação" do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante, efetivamente aprovado pelos parlamentares. Conferir: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

17. <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7275778&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

18. O projeto apensado previa "que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências". Conferir: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517> . Acesso em 16 maio 2018.

19. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017 . Acesso em 16 maio 2018.

20. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/132413> . Acesso em 16 maio 2018.

21. Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do Senador Dário Berger (Parecer nº 51, de 2018 – PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link:

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7652589&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018. O texto final aprovado pode ser baixado neste link:

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

22. O texto pode ser baixado no seguinte link:

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018."

É o que ocorre quando analfabetos funcionais se metem a fazer e/ou alterar leis em nosso país.

Por fim, deve ser reconhecido o concurso material de delitos entre os assaltos narrados na denúncia, e não continuidade delitiva.

Não se pode confundir reiteração criminosa com continuidade delitiva se o agente faz do crime um modo de auferir dinheiro. Trata-se de contumácia criminosa e não de crime continuado.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS' – CRIME DE ROUBO – PRÁTICAS SUCESSIVAS – CRIMINALIDADE HABITUAL – MERA REITERAÇÃO DE CRIMES – DESCARACTERIZAÇÃO DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE 'HABEAS CORPUS' – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO - A prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem, mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva. O assaltante que assim procede não pode fazer jus ao benefício derivado do reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. A mera reiteração no crime – que não se confunde nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado – traduz eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social daquele que a pratica.

Precedentes - O reconhecimento do crime continuado - que afasta a incidência da regra do cúmulo material das penas - reveste-se de caráter excepcional, devendo, para os efeitos jurídico-penais dele resultantes, ficar plenamente configurado em todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção conceitual. O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de 'habeas corpus'. Precedentes" (STF - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 118.460 SÃO PAULO)

Na mesma esteira de raciocínio, a 2ª. Turma do STF, com a relatoria da Min. Ellen Gracie, assevera que "Para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos. 2. Constatada a reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes. 3. A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício àqueles delinquentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma espécie, deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de receber a benesse" (STF HC 101049/RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 04/05/2010 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010

E em decisão recente, o STJ, reconhecendo as consequências da habitualidade criminosa, concluiu que "Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado....." (STJ; HC 128.663; Proc. 2009/0027662-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/08/2010; DJE 13/09/2010)

A impossibilidade fica ainda mais evidente quando os roubos envolvem vítimas diferentes, como no caso em tela:

"Inadmissibilidade de crime continuado quando o agente pratica roubos contra vítimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido cometidos em tempo próximo, e em condições de lugar e maneira de execução idênticas" (recurso extraordinário n. 82.297-SP, DJU de 2.4.1976, pág. 2.227; habeas corpus n. 54.015-RJ, DJU de 9.4.1976, pág. 2.385).

A violação a bens jurídicos personalíssimos quebra e impede a semelhança de ações indutoras da continuação. No caso do roubo, o bem jurídico é necessariamente lesado na pessoa do titular ou detentor do bem. "Não é possível, tratando-se de diversas pessoas, que a lesão praticada contra uma seja continuação da cometida contra outra" (Damásio E. de Jesus, "Roubo não admite continuação", publicado em O Estado de S. Paulo, ed. de 28.3.1976, p. 46).

O bem jurídico é lesado de forma descontínua. Anote-se, além disso, que o reconhecimento da continuidade delitiva se prende a um fator de equidade, apurável em concreto (cf. Manoel Pedro Pimentel, "Do crime continuado", conclusões IV/V). A crescente criminalidade violenta; a prática de roubos com habitualidade por agentes; exigências atuais de maior defesa social - tudo isto também leva a negar a continuidade entre os roubos contra vítimas diversas, evitando-se que a pluralidade de roubos se transforme num verdadeiro ideal ou estímulo para o assaltante, visando à ulterior unificação de penas. O agente que cometesse um só roubo, seria proporcionalmente punido com muito maior rigor do que o que cometesse dois deles contra vítimas diferentes em suposta continuação.

Portanto, por razões teóricas (quebra do elo objetivo de continuação nos roubos contra vítimas diversas) e por razões práticas (imperativos de defesa social), não se pode reconhecer a continuidade entre roubos com pluralidade de sujeitos passivos.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhes as penas.

Primeiro, o acusado EDUARDO:

Quanto ao primeiro assalto, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, considerando as circunstâncias e a gravidade (em concreto) do delito, bem como os antecedentes a personalidade do réu. Com efeito, o acusado e seus comparsas agiram de forma premeditada e demonstraram enorme ousadia, pois abordaram a vítima, uma mulher, em plena via pública, durante a manhã, utilizando um veículo Fiat Uno no apoio à empreitada criminoso. Permaneceram em poder da ofendida por cerca de 15 minutos, obrigando-a a realizar transferência bancária (sem sucesso) e subtraindo R\$ 600,00 em dinheiro e seu relógio. Ainda subtraíram seu veículo Pajero, posteriormente recuperado danificado e sem placas, causando-lhe enorme prejuízo material (cerca de R\$ 10.000,00). Se não bastasse, o acusado é envolvido com a criminalidade desde menor, tendo cumprido medida socioeducativa internação na Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas, por três vezes. Há que se considerar ainda a personalidade deformada do acusado, que o leva a reiteradamente violar a Lei.

Observe-se que o conceito de maus antecedentes não se confunde com o de primariedade, que diz respeito à ausência de condenação transitada em julgado, sendo certo que para a configuração dos maus antecedentes basta que se verifique a participação do agente em práticas outras que se mostrem repreensíveis.

Face à atenuante da menoridade, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Não há que se falar em atenuante da confissão, pois o acusado mentiu em Juízo, ao negar a participação do corréu Matheus no assalto.

A confissão que vale como atenuante é apenas aquela cabal, integral, envolvendo todas as circunstâncias do delito, e com ânimo de arrependimento.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Acusado que admite apenas parcialmente a autoria do delito - Impossibilidade de reconhecimento: - Impossível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, quando o acusado admite apenas parcialmente a autoria do delito, pois tal benefício exige a admissão integral (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.366.915/1 - Birigüi - 6ª Câmara - Relator: Almeida Sampaio - 30.6.2003 - V. U. (Voto nº 8.415) (TACrim - Ementário nº 47, NOVEMBRO/2003, pág. 06)

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Quanto ao segundo assalto, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, considerando as circunstâncias e a gravidade (em concreto) do delito, bem como os antecedentes a personalidade do réu. Com efeito, o acusado e seus comparsas demonstraram enorme ousadia, pois abordaram a vítima, em plena via pública, durante a manhã utilizando o veículo Fiat Uno e o veículo Pajero (que acabara de ser roubado da vítima Helia) no apoio à empreitada criminoso. Subtraíram seu veículo Onix, além de suas ferramentas de trabalho, causando-lhe grande prejuízo material (cerca de R\$ 3.000,00). Se não bastasse, o acusado é envolvido com a criminalidade desde menor, tendo cumprido medida socioeducativa internação na Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas, por três vezes. Há que se considerar ainda a personalidade deformada do acusado, que o leva a reiteradamente violar a Lei.

Observe-se que o conceito de maus antecedentes não se confunde com o de primariedade, que diz respeito à ausência de condenação transitada em julgado, sendo certo que para a configuração dos maus antecedentes basta que se verifique a participação do agente em práticas outras que se mostrem repreensíveis.

Face à atenuante da menoridade, retorno as penas ao patamar mínimo legal.

Não há que se falar em atenuante da confissão, pois o acusado mentiu em Juízo, ao negar a participação do corréu Matheus no assalto.

A confissão que vale como atenuante é apenas aquela cabal, integral, envolvendo todas as circunstâncias do delito, e com ânimo de arrependimento.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Acusado que admite apenas parcialmente a autoria do delito - Impossibilidade de reconhecimento: - Impossível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do CP, quando o acusado admite apenas parcialmente a autoria do delito, pois tal benefício exige a admissão integral (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.366.915/1 - Birigüi - 6ª Câmara - Relator: Almeida Sampaio - 30.6.2003 - V. U. (Voto nº 8.415) (TACrim - Ementário nº 47, NOVEMBRO/2003, pág. 06)

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa.

Em relação ao acusado MATHEUS:

Quanto ao primeiro assalto, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, considerando as circunstâncias e a gravidade (em concreto) do delito, bem como os antecedentes a personalidade do réu. Com efeito, o acusado e seus comparsas agiram de forma premeditada e demonstraram enorme ousadia, pois abordaram a vítima, uma mulher, em plena via pública, durante a manhã, utilizando um veículo Fiat Uno no apoio à empreitada criminoso. Permaneceram em poder da ofendida por cerca de 15 minutos, obrigando-a a realizar transferência bancária (sem sucesso) e subtraindo R\$ 600,00 em dinheiro e seu relógio. Ainda subtraíram seu veículo Pajero, posteriormente recuperado danificado e sem placas, causando-lhe enorme prejuízo material (cerca de R\$ 10.000,00). O acusado é portador de péssimos antecedentes, já condenado por furto, roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo (certidões de fls. 149/154), tendo cometido novo e grave delito apenas 04 meses após sair da cadeia, quando ainda cumpria pena anterior em regime aberto. Se não bastasse, o acusado é envolvido com a criminalidade desde menor, tendo cumprido medida socioeducativa internação na Fundação Casa, por dois anos, pela prática de atos infracionais equiparados a furto, porte de arma e roubo. Há que se considerar ainda a personalidade deformada do acusado, que o leva a reiteradamente violar a Lei.

Face à agravante da reincidência específica (3ª Vara Criminal de Guarulhos, fls. 152 - não considerada na primeira fase da dosimetria), aumento a pena pela metade, totalizando 09 anos de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa.

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 15 anos de reclusão, e pagamento de 36 dias-multa.

Quando segundo assalto, verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, considerando as